

1013897-16.2022.8.26.0032

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Sérgio Ricardo Biella

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 4ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... e do consumidor. Recurso especial. Roubo de talonário de cheques durante transporte. Empresa terceirizada. Uso indevido dos cheques por terceiros posteriormente. Inscrição do correntista nos registros de proteção ao crédito. Responsabilidade do banco. Teoria do risco profissional. Excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços. art. 14, § 3º, do CDC. Ônus da prova. Segundo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

4ª Vara Cível

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba - SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1013897-16.2022.8.26.0032 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1013897-16.2022.8.26.0032

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Josefa Gerlane Costa dos Santos

Requerido:

Banco Pan S/A

Justiça Gratuita

Vistos.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por JOSEFA GERLANE COSTA DOS SANTOS, em face de BANCO PAN S.A. Alegou, em suma, que é titular da conta digital nº 017998943-1, agência nº 001, do Banco Requerido, desde janeiro de 2022, tendo recebido o respectivo cartão em sua residência, o qual desbloqueado em 5 de julho de 2022, ocasião em que fez um PIX de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) para sua conta junto ao banco réu, bem como outro PIX no valor de R\$15,00 (quinze reais), para a conta de titularidade de sua filha. Ocorre que, após abastecer seu carro e tentar passar o cartão, teve sua transação recusada por três vezes. Assim, trocou a senha no aplicativo do Banco e, ao consultar seu saldo, notou que constava apenas R\$ 4,00. Em seguida, ao verificar o extrato da conta, observou que foram feitos dois PIX e uma transferência, sendo um no valor de R\$ 299,89 e outro no valor de R\$ 298,79, e a transferência bancária no importe de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), operações estas que não realizou. Em razão disso, requer a procedência da ação, para condenar o réu a lhe restituir o valor de R\$ 868,68 (oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos), a título de danos materiais, bem como a indenizá-la, por danos morais, no importe de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) (fls. 01/16). Juntou procuração e documentos (fls.

17/28).

Por decisão de fls. 47, foi deferido o benefício da justiça gratuita à autora.

Citado (fl. 51), o requerido apresentou contestação (fls. 52/71) e acostou documentos (fls.72/73). Preliminarmente, alegou sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduziu, em síntese, que a parte autora jamais ficou sem acesso à sua conta. Sustenta que realizou minuciosa análise técnica a qual atestou a inexistência de irregularidades e que a parte autora realizou, de fato, as transferências em questão, eis que as referidas transações ocorreram mediante inserção de login e senha no aplicativo do banco. Afastou as alegações de fraude contidas na exordial. Por fim, alegou culpa exclusiva da vítima e fato de terceiros, de modo que não há dano a ser indenizado. Assim, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Houve réplica (fls. 77/81).

É O RELATÓRIO.
FUDAMENTO E DECIDO.

Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a matéria litigiosa é unicamente de direito e porque os fatos encontram-se comprovados pelos documentos juntados aos autos, de sorte que não há necessidade de dilação probatória.

Alegou a parte requerente, em suma, que no dia 05/07/2022 tomou conhecimento de que pessoas mal-intencionadas utilizaram de seus dados para transferência através de PIX em seu nome junto ao banco réu. Entrou em contato com a central de atendimento do réu para solicitar o bloqueio das eventuais transações feitas na sua conta através da operação PIX. Em consulta a sua conta, verificou que haviam sido feitos dois PIX e uma transferência bancária. Tais operações derivam de fraude. Não realizou as transações. As tentativas de acordo junto ao requerido restaram infrutíferas. Houve falha na prestação dos serviços. Requereu, assim, a procedência dos pedidos, para condenar a ré a lhe ressarcir o valor de R\$ 868,68, além de danos morais no valor de R\$10.000,00.

O requerido, por sua vez, sustentou, em síntese, a inexistência de ato ilícito. Para que os débitos contestados fossem realizados, as transações teriam de ser efetuadas mediante os dados do cartão e digitação de senha pessoal e intransferível ds requerente. O suposto fraudador, para realizar transações, teria de saber a senha pessoal e intransferível da autora. Não havendo vício na prestação de serviço, não há que se falar em responsabilidade. As transações indevidas foram realizadas em razão da eventual negligência da autora na guarda de sua senha de forma segura. Não praticou conduta capaz de gerar danos à requerente, pois as transações foram realizadas por ela. Houve culpa exclusiva da requerente e fato de terceiro. Pugnou pela improcedência dos pedidos.

No mérito, os pedidos são parcialmente procedentes.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à espécie vertente, porquanto as partes se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor, estatuídos nos artigos 2º e 3º do aludido diploma legal.

A patente vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da parte autora e a verossimilhança dos fatos narrados no petitório inicial autorizam a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor), tornando-se incumbência da parte requerida comprovar o funcionamento de seus serviços com qualidade e regularidade adequados à sua natureza, o que não foi feito nos autos.

Dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Se não provada pelo fornecedor de serviços a hipótese excludente, torna-se este objetivamente responsável pela reparação dos danos causados pelo vício na prestação de serviço, como consequência do risco da atividade desenvolvida.

Malgrado alegue o banco réu regularidade nas transações impugnadas, não se desincumbiu de comprovar que tais transações foram realizadas pela autora, através de liberação por senha digital de dispositivo eletrônico por ela cadastrada ou através de terminal eletrônico com uso de cartão e senha, ônus que lhe incumbia, em decorrência da relação consumerista e a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

O requerido não trouxe aos autos qualquer prova capaz de demonstrar a regularidade das transações, prova esta que não seria difícil de produzir, ante as ferramentas tecnológicas que os bancos atualmente possuem.

Outrossim, forçoso convir que é impossível a produção de prova negativa por parte da consumidora lesada. Se ela alega que não efetuou as transações via PIX, não tem meios para provar isso. Nesse sentido, o Boletim de Ocorrência de fls. 21/22 confere plausibilidade às alegações da requerente. De outro lado, o requerido, como dito, possui ferramentas para provar a legitimidade das transações, o que não ocorreu no caso em apreço.

Segundo ensinamentos de Cláudia Lima Marques, Antonio Herman V. Benjamin e Bruno Miragem, "A responsabilidade das entidades bancárias, quanto aos deveres contratuais de cuidado e segurança, é pacífica, em especial a segurança nas retiradas, assinaturas falsificadas e segurança nos cofres. Já em caso de falha externa e total do serviço bancário, com abertura de conta fantasma com o CPF da 'vítima-consumidor' e inscrição no Serasa (dano moral), usou-se a responsabilidade objetiva da relação de consumo (aqui totalmente involuntária), pois aplicável o art. 17 do CDC para transformar este terceiro em consumidor e responsabilizar o banco por todos os danos (materiais e extrapatrimoniais) por ele sofridos. Os assaltos em bancos e a descoberta das senhas em caixas eletrônicos também podem ser considerados acidentes de consumo e regulados ex vi art. 14 do CDC. (...)” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, p. 482)

Principalmente por sua rápida proliferação no mercado, as fraudes junto às instituições financeiras e fornecedores em geral não só é fato previsível como também evitável, além de ser inerente ao risco da atividade que essas instituições exercem.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vem se manifestando reiteradamente nesse sentido:

“Não se pode esquecer, doutro turno, que, para a culpa civil, a mais leve é suficiente. Inviável afastar a responsabilidade do Banco que, necessariamente, conhecedor das atividades fraudulentas com o uso de documentos falsos, deveria desenvolver maiores cuidados e providências para evitar a abertura de contas e a entrega de talões de cheques, a propiciar dessa forma o uso ilícito e em prejuízo daquelas pessoas, cujos nomes foram indevidamente utilizados. E se não tem condições de controlar esse serviço, para torná-lo, totalmente, seguro e confiável, assume o risco pelo resultado lesivo, tão-só pelo seu exercício e pela persistência em prestá-la. Nesse derradeiro ângulo a responsabilidade do Banco apelado também se apresenta no ângulo objetivo. Em adendo, e, ainda, na perspectiva da responsabilidade objetiva, cumpre anotar a aplicabilidade à espécie, da lei 8.078/90, art. 14. O Banco fornece serviços, abrangendo não só aqueles que com ele contratam, mas compreendendo todos os outros, igualmente, sujeitos e alcançados por suas atividades, que, mesmo indiretamente, sofrem prejuízos. Ao operacionalizar a abertura da conta corrente e entregar os talões de cheques, ainda que diverso o verdadeiro contratante, a instituição de crédito recorrente, na realidade, firmou uma relação de consumo com o autor, exatamente por sua desídia e imprevidência, ou por ter assumido o risco de desenvolver uma atividade, cuja segurança não pode controlar” (TJSP, Ap.160.019-4/0-00-SP, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcus Andrade, 7.11.02, JTJ 262/138-142).

Deve-se atentar para a recorrência com que tais fatos ocorrem no mercado o que lhes retira o caráter fortuito que excluiria a responsabilidade pelos danos.

A distinção entre o fortuito externo e o fortuito interno, que não exclui a responsabilidade, é muito bem delineada pelo Superior Tribunal de Justiça em situações análogas:

“Direito processual civil e do consumidor. Recurso especial. Roubo de talonário de cheques durante transporte. Empresa terceirizada. Uso indevido dos cheques por terceiros posteriormente. Inscrição do correntista nos registros de proteção ao crédito. Responsabilidade do banco. Teoria do risco profissional. Excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços. art. 14, § 3º, do CDC. Ônus da prova. Segundo a doutrina e a jurisprudência do STJ, o fato de terceiro só atua como excludente da responsabilidade quando tal fato for inevitável e imprevisível. O roubo do talonário de cheques durante o transporte por empresa contratada pelo banco não constituiu causa excludente da sua responsabilidade, pois se trata de caso fortuito interno. Se o banco envia talões de cheques para seus clientes, por intermédio de empresa terceirizada, deve assumir todos os riscos com tal atividade. O ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC. Recurso especial provido” (REsp 685.662-RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 10.11.05)

Tal entendimento já foi, inclusive, objeto de Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesta senda, inequívoco direito da autora de ser ressarcida materialmente pelos valores objeto de fraude.

De outro lado, no tocante aos danos morais, fato é que a requerente sequer chegou a especificar a causa da indenização pretendida, não tendo havido no caso qualquer

ofensa à sua honra ou apontamento junto aos cadastros de inadimplentes, de modo que os transtornos suportados por ela, conquanto inconvenientes e não desejáveis, não extrapolam a esfera do mero aborrecimento e não são suscetíveis de reparação.

Sobre esse ponto, SÉRGIO CAVALIERI FILHO pondera que o “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Programa de Responsabilidade Civil, 3.^a Edição, pág. 89, Malheiros Editores).

Oportuno, ainda, relembrar as lições do grande jurista português Rabindranath V. A. Capelo de Sousa: “Trata-se aqui de prejuízos insignificantes ou de diminuto significado, cuja compensação pecuniária não se justifica, que todos devem suportar num contexto de adequação social, cuja ressarcibilidade estimularia uma exagerada mania de processar e que, em parte, são pressupostos pela cada vez mais intensa e interactiva vida social hodierna. Assim, não são indenizáveis os diminutos incômodos, desgostos e contrariedades, embora emergentes de actos ilícitos, imputáveis a outrem e culposos”. (O Direito Geral de Personalidade, Coimbra Editora, 1995, págs.555/556).

No mais, prevalece na jurisprudência o entendimento de que apenas é passível de reparação o autêntico dano moral, haja vista que mero aborrecimento, dissabor, frustração ou mesmo o mero descumprimento contratual não são suscetíveis de configurar ofensa moral indenizável: “O mero descumprimento contratual não enseja reparação moral, devendo haver comprovação de que os dissabores experimentados ultrapassaram o mero aborrecimento para que se configurem danos morais”. (AgInt no REsp 1703645/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018).

De rigor, portanto, a parcial procedência dos pedidos.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por JOSEFA GERLANE COSTA DOS SANTOS em face de BANCO PAN S.A, apenas para condenar o requerido a restituir à autora a quantia de R\$ 868,68 (oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos – fls. 25/27), corrigida monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a data de cada transação, e acrescida de juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação.

Sucumbentes autora e réu, cada qual arcará com metade das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, cada qual fixados em 15% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade.

P.I.C.

Araçatuba, 15 de dezembro de 2022.

SÉRGIO RICARDO BIELLA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA